

الظروف الاقتصادية الطارئة وإعادة التوازن المالي للعقد الإداري في ضوء فكرة التوقع المشروع معالجة المشرع المصري لآثار تحرير سعر الصرف نموذجاً

الدكتور يوسف عبد المحسن عبد الفتاح

دكتوراه القانون العام

كلية الحقوق - جامعة القاهرة

تمهيد وتقسيم:

إنه لما كان الأصل أن الهدف الأسمى والغاية المرجوة من كافة تصرفات جهة الإدارة -وفي القلب منها العقود الإدارية التي تبرمها- هو الحفاظ على دوام سير المرفق العام بانتظام واطراد، فإن تلك الغاية يقابلها غاية أخرى لدى المتعاقدين معها، تتمثل في استهدافهم تحقيق بعض المكاسب المادية التي يسعون إليها، بوصف أن تلك المكاسب تعد من قبيل التوقعات المشروعة التي دفعتهم إلى إبرام هذه التعاقدات بالأساس، وفقاً لدراسات الجدوى التي سبق أن أعدوها في إطار البيئة الاقتصادية السائدة وقت إبرامها.

إلا أنه لما كانت تلك البيئة الاقتصادية قد يطرأ عليها من الظروف والمتغيرات الاستثنائية ما لم يكن في مقدور المتعاقد مع الإدارة توقعه أثناء التعاقد، وبما قد تحدثه تلك الظروف من إخلال بالتوازن المالي للعقد الإداري، وما يترتب عليه بالتبعية من إخلال أو عَصَف بالتوقعات المشروعة التي كان المتعاقد مع الإدارة يرجوها من وراء تعاقد معها، بما يُوجبُ على جهة الإدارة هنا، التدخل -رضاءً أو قضاءً- للعمل على إعادة التوازن المالي للعقد الإداري.

ذلك أن إعادة التوازن المالي للعقد الإداري في هذه الحالة، يعد مظهرًا مركَّبًا من مظاهر «الأمن القانوني» الواجب على جهة الإدارة مراعاتها، سواء تجاه حماية التوقعات المشروعة للمتعاقد معها، أو تجاه الحفاظ على استقرار عمل المرفق العام ذاته بانتظام واطراد، إذ إن إقامة ذلك التوازن، يؤدي إلى ضمان بيئة استثمارية مستقرة للمتعاقد مع الإدارة، لا يخشى فيها من تلك التقلبات الاقتصادية غير المتوقعة، التي لا يد له فيها، مع كونها في الوقت ذاته تعصف بتوقعاته المشروعة، كما أنه من ناحية مقابلة، يمكن المتعاقد من تنفيذ تعاقد على الوجه الأمثل، للحفاظ على استقرار وديمومة أداء المرفق العام لمهامه بانتظام واطراد مَنشودين.

وما أجملاه فيما سبق، نتناوله بمزيد من التفصيل والبيان في هذه الورقة البحثية، عبر مباحث ثلاثة، يتناول أولها، بيان ماهية نظرية الظروف الطارئة وشروط إعمالها والآثار المترتبة على تحققها، ويتناول ثانيها، بيان الأساس القانوني لإعادة التوازن المالي للعقد الإداري في ضوء التوقع المشروع، ثم يتناول ثالثها، بيان المعالجة

القضائية والتشريعية للظروف الاقتصادية الطارئة المترتبة على تعديل سعر الصرف، وذلك عبر مطلبين، يتعرض الأول منهما لبيان موقف القضاء الإداري المصري من اعتبار تقلبات سعر الصرف ظرفاً طارئاً، ثم يعرّج الثاني منهما على المعالجة التشريعية لآثار تحرير سعر الصرف بمقتضى قانون التعويضات المصري رقم ٨٤ لسنة ٢٠١٧، وذلك كله وفقاً للتفصيل التالي:

المبحث الأول

مفهوم نظرية الظروف الطارئة وشروط إعمالها وآثار تحققها

تعد العقود الإدارية من الوسائل الهامة التي تلجأ إليها جهة الإدارة في الدولة المعاصرة في سبيل تسييرها للمرفق العام، ذلك أنه من الصعوبة بمكان في ظل تشعب حاجيات المجتمع وتعدد متطلبات إشباعها، أن تقوم الدولة بإشباع تلك الحاجيات بنفسها، ومن هنا غالباً ما تعتمد في إشباع تلك الحاجيات المتنوعة على إبرام العديد من العقود الإدارية المختلفة، بما يضمن حسن سير المرافق العامة بانتظام واطراد، وبما يكفل في النهاية أداءها لمهامها وخدماتها بالصورة المتوخاة منها.

وإنه لما كانت تلك الغاية المتمثلة في ضمان حسن سير المرافق العامة بانتظام واطراد، قد أضفت على العقود الإدارية طبيعة خاصة أو استثنائية من حيث طبيعة الالتزامات المتبادلة بين جهة الإدارة المتعاقدة وبين المتعاقدين معها، كما أنه لما كانت تلك العقود قد يطرأ على تنفيذها بعض الظروف غير المتوقعة، والتي قد تحدث إخلالاً جسيماً باقتصاديات العقد وتوازنه المالي، بما قد يترتب على عدم معالجة تلك الظروف من تأثير سلبي على تنفيذ تلك العقود، ومن ثم الإخلال بسير المرفق العام ذاته عبر قصور تقديمه للخدمات المنوط به تقديمها على الوجه المنشود، هذا من ناحية، كما يترتب على ذلك الإهمال أيضاً -ومن ناحية أخرى- الإضرار المادي بالمتعاقدين مع جهة الإدارة، لذا، فإن كل تلك الأسباب مجتمعة -وفي القلب منها تلك الطبيعة الاستثنائية للعقود الإدارية فضلاً عن مبادئ العدالة وغيرها- تحتم على جهة الإدارة التدخل لتعويض المتعاقدين معها عما ألمّ به من آثار تلك الظروف الطارئة، بغية إعادة التوازن المالي لتعاقداتها مرة أخرى.

وهو ما يفيد - وكما يقرر بعض الفقه - أن الدور الذي تلعبه تغير الظروف في العقود الإدارية، يضافي على العقد الإداري حركية وديناميكية، على خلاف ثبات واستقرار العقد المدني، ومن ثم فإذا بدا العقد الإداري أثناء تنفيذه نظاماً حياً ومتطوراً، باستمرار، فإن الفضل في ذلك يرجع إلى فكرة تغير الظروف وأثرها على العقد الإداري^(١)، والتي تعد بدورها أثراً من آثار الطبيعة الاستثنائية للعقود الإدارية، والقائمة بالأساس على استخدام جهة الإدارة لسلطات وامتيازات القانون العام تجاه المتعاقدين معها^(٢)، بوصفه المعيار المميز لتلك العقود عن غيرها من عقود القانون الخاص، وفقاً لما أصبح مستقراً عليه في هذا الشأن في الفقه والقضاء^(٣).

١ في هذا المعنى، د. سعاد الشرقاوي- العقود الإدارية- الطبعة الثانية -دار النهضة العربية - بدون سنة نشر، ص ٣٩٠.
٢ يراجع للمزيد حول آثار استخدام الجهة الإدارية لوسائل وامتيازات السلطة العامة على العقود الإدارية وعلى تنفيذها، د. سعاد الشرقاوي- العقود الإدارية- مرجع سابق ص ٣٨٦ وما بعدها.
٣ يراجع حول تطور موقف الفقه والقضاء الإداري من تحديد المعيار المميز للعقود الإدارية، حتى استقرار الأمر على معيار استخدام جهة الإدارة به لوسائل وامتيازات السلطة العامة، بوصفها شروطاً استثنائية غير مألوفة في نطاق القانون الخاص، د. علي سليمان الطماوي- التحكيم في

مفهوم نظرية الظروف الطارئة:

يقصد بنظرية الظروف الطارئة، أن تطرأ خلال مدة تنفيذ العقد حوادث أو ظروف استثنائية عامة، لم تكن فى حسابان المتعاقد عند إبرام العقد، يترتب عليها اختلال اقتصاديات العقد اختلالاً جسيماً، فتجعل تنفيذه أكثر كلفة وإرهاقاً، وإن لم يكن مستحيلاً، فإذا ما توافرت هذه الشروط مجتمعة، التزمت جهة الإدارة المتعاقدة -رضاءً أو قضاءً- بإعادة التوازن المالي للعقد الإداري، من خلال تعويض المتعاقد معها عما ألمَّ به من جراء تلك الظروف - مع وجوب استمرار المتعاقد معها في تنفيذ التزاماته التعاقدية- ضماناً لتنفيذ العقد على الوجه الذي يكفل حسن سير المرافق العامة بانتظام واطراد^(١).

نظرية الظروف الطارئة في قضاء مجلس الدولة المصري:

لقد تناولت المحكمة الإدارية العليا نظرية الظروف الطارئة في العديد من أحكامها، مبينة مفهومها وضوابط وعلة إعمالها، ونطاق الآثار المترتبة على حدوثها، إذ قضت بأن المقصود بنظرية الظروف الطارئة، «أن تطرأ خلال مدة تنفيذ العقد الإداري حوادث أو ظروف طبيعية أو اقتصادية، أو من عمل جهة إدارية غير الجهة المتعاقدة، أو من عمل إنسان آخر، لم تكن فى حسابان المتعاقد عند إبرام العقد، ولا يملك لها دفْعاً، ومن شأنها أن تنزل به خسائر فادحة تختل معها اقتصاديات العقد اختلالاً جسيماً، فإذا ما توافرت هذه الشروط مجتمعة، التزمت جهة الإدارة المتعاقدة بمشاركة المتعاقد معها فى تحمل نصيب من خسائره، ضماناً لتنفيذ العقد على الوجه الذي يكفل حسن سير المرافق العامة بانتظام واطراد، فنظرية الظروف الطارئة تقوم على فكرة العدالة المجردة التي هى قوام القانون الإداري، كما أن هدفها تحقيق المصلحة العامة، فرائد الجهة الإدارية هو كفالة حسن سير المرافق العامة باستمرار وانتظام، وحسن أداء الأعمال والخدمات المطلوبة وسرعة إنجازها، كما أن هدف المتعاقد مع الإدارة هو المعاونة في سبيل المصلحة العامة، ذلك بأن يؤدي التزامه بأمانة وكفاية لقاء ربح أو أجر عادل، وهذا يقتضي من الطرفين التساند والمشاركة للتغلب على ما يعترض تنفيذ العقد من صعوبات، وما يصادفه من عقبات، ويكون من حق المتعاقد المضار أن يطلب من الطرف الآخر مشاركته في هذه الخسارة التي تحمّلها، فيعوضه عنها تعويضاً جزئياً، وهذا التعويض لا يشمل الخسارة كلها ولا يغطي إلا جزءاً من الأضرار التي تعين المتعاقد، فإن المدين ليس له أن يطالب بالتعويض بدعوى أن أرباحه قد نقصت، أو لفوات كسب ضاع

العقود الإدارية بين النظرية والتطبيق دراسة مقارنة- الطبعة الثانية- دار النهضة العربية ٢٠١٧، ص ٣٠-٣٣، كما يراجع أيضاً في ذات الصدد، د. ثروت بدوي - النظرية العامة في العقود الإدارية - دار النهضة العربية ١٩٩٤، ص ٥٦، وكذلك بحث سيادته: المعيار المميز للعقد الإداري- مجلة القانون والاقتصاد - السنة ٢٧، سبتمبر ١٩٥٧ ص ١١٧ وما بعدها، كما يراجع أيضاً حكم محكمة القضاء الإداري في ١٩٥٦/١٢/٩، طعن رقم ٨٧٠ لسنة ٥ ق، المجموعة، السنة ١١، ص ٧٦، وكذلك حكم المحكمة الإدارية العليا في ٢٠٠٨/٤/١٥، طعن رقم ١٢٨٣٧ لسنة ٥٠ ق. عليا، ومشار إلى ما سبق لدى د. علي سليمان الطماوي- التحكيم في العقود الإدارية بين النظرية والتطبيق -مرجع سابق، ذات الصفحات.

١ () للمزيد حول نظرية الظروف الطارئة وتنشأتها وتطورها، يراجع على سبيل المثال، د. جابر جاد نصار - الوجيز في العقود الإدارية- دار النهضة العربية طبعة ٢٠٠٠، ص ٢٥٧ وما بعدها، ود. محمد عبد العال السناري- النظرية العامة للعقود الإدارية دراسة مقارنة- دار النهضة العربية- دون سنة نشر، ص ٢٩٨ وما بعدها، ود. علي محمد علي عبد المولى- الظروف التي تطرأ أثناء تنفيذ العقد الإداري- دراسة مقارنة- رسالة دكتوراه- كلية الحقوق جامعة عين شمس ١٩٩١، ص ١٤ وما بعدها، ود. أحمد يسري- ترجمة أحكام المبادئ في القضاء الإداري الفرنسي- الطبعة العاشرة - دار الفكر الجامعي بالإسكندرية ١٩٩٥، ص ٢٣٥ وما بعدها، وكذلك ص ١٨٠ وما بعدها، ود. محمد الشافعي أبو راس- العقود الإدارية- بدون سنة أو دار نشر، ص ١٠٩ وما بعدها، ود. صالح إبراهيم المتيوتي ود. مروان محمد محروس المدرس- القانون الإداري - الكتاب الثاني - مطبوعات جامعة البحرين ٢٠٠٧، ص ١٦٧ وما بعدها، ود. محمد عبد الحميد أبو زيد - المرجع في القانون الإداري- الطبعة الثانية ٢٠٠٧، ص ٤١٩ وما بعدها.

عليه، كما أنه يجب أن تكون الخسارة واضحة متميزة، ومن ثم يجب لتقدير انقلاب اقتصاديات العقد واعتبارها قائمة، أن يدخل في الحساب جميع عناصر العقد التي تؤثر في اقتصادياته، واعتبار العقد في ذلك وحدة «واحدة» ويفحص في مجموعه لا أن ينظر إلى أحد عناصره فقط، بل يكون ذلك بمراعاة جميع العناصر التي يتألف منها، إذ قد يكون بعض هذه العناصر مجزئاً ومعوّضاً عن العناصر الأخرى التي أدت إلى الخسارة⁽¹⁾.

شروط أعمال نظرية الظروف الطارئة:

يمكن من خلال البيان السابق لمفهوم نظرية الظروف الطارئة، الوقوف على شروط أعمال مقتضاها، من حيث وجوب تدخل جهة الإدارة لإعادة التوازن المالي للعقد الإداري، نتيجة ما ألمّ بالمتعاقد معها من جراء تلك الظروف، ويمكن إجمال تلك الشروط فيما يلي:

1- أن يحدث أثناء مدة تنفيذ العقد ظرف استثنائي عام، وهذا الظرف الطارئ قد يكون ظرفاً اقتصادياً، كتقلب أسعار صرف العملة عما كانت عليه وقت التعاقد بما لم يكن في مقدور المتعاقد توقعه، كما قد يكون ظرفاً طبيعياً، كفيضان أو زلزال أو غيره، بما يجعل التنفيذ أكثر كلفة ومشقة، وقد يكون ظرفاً سياسياً، كنشوب حرب، بل وربما يكون ذلك الظرف ناشئاً عن فعل جهة إدارية أخرى غير الجهة المتعاقدة، إذ إنه لو كان مرده إلى فعل جهة الإدارة المتعاقدة، لكنّا في نطاق أعمال نظرية عمل الأمير لا نظرية الظروف الطارئة، شريطة أن ينتج عن أيٍّ مما سبق من صور لتلك الظروف، إخلال جسيم باقتصاديات العقد، فيصبح تنفيذه أكثر كلفة ومشقة، ولكنه ليس مستحيلاً، إذ إنه حال استحالة التنفيذ، يخرج الأمر من نطاق أعمال نظرية الظروف الطارئة، إلى نطاق أعمال نظرية القوة القاهرة⁽²⁾.

وعلى هذا الشرط تؤكد المحكمة الإدارية العليا بأنه «يشترط لتطبيق نظرية الحوادث الطارئة عدة شروط : أولها: أن تظهر خلال تنفيذ العقد الإداري حوادث أو ظروف استثنائية، طبيعية كانت أو اقتصادية أو إدارية،

١ حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية في ١٩٩٣/٤/٤، طعن رقم ٤٥٩ لسنة ٣٥ ق. عليا، وفي ذات الصدد أيضاً حكمها في الطعن رقم ٤٦٦٩ و ٥٠٨٧ لسنة ٤١ ق. عليا بجلسة ١٩٩٧/١١/٢٥، وحكمها في ١٩٨٧/٥/١٦، طعن رقم ٣٥٦٢ لسنة ٢٩ ق. عليا، وحكمها في ١٩٨٧/٥/١٦، طعن رقم ٣٥٦٢ لسنة ٢٩ ق. عليا، وحكمها في ١٩٨٥/١١/٣٠، طعن رقم ٢٥٤١ لسنة ٢٩ ق. عليا، وحكمها في ٢٠٠١/٥/٨، طعن رقم ٥٩٥٥ لسنة ٤٣ ق. عليا، وحكمها في ١٩٦٧/١١/٢٥، طعن رقم ١١٨٦ لسنة ١٠ ق. عليا.

٢ يقصد بالقوة القاهرة، تلك الحوادث التي يستحيل دفعها، ولا يد لأحد طرفي العقد بها، وتؤدي إلى استحالة تنفيذ الالتزامات التعاقدية، بما يترتب على ذلك من إعفاء المتعاقد من تنفيذ التزاماته، يراجع في هذا المعنى، د. صالح إبراهيم المتينقي ود. مروان محمد محروس المدرس- مرجع سابق، ص ١٧٧.

كما أنه ربما تجدر الإشارة هنا أيضاً إلى أن هناك بعض النظريات قريبة الشبه بنظرية الظروف الطارئة، ولكنها في الواقع تختلف عنها طبيعة وآثراً، وربما أن أكثر هذه النظريات تشابهاً بنظرية الظروف الطارئة، نظريتنا عمل الأمير و الصعوبات المادية غير المتوقعة.

ويقصد بنظرية عمل الأمير، «اتخاذ إجراء عام أو خاص من جانب «جهة الإدارة المتعاقدة»، ولم يكن متوقعاً وقت التعاقد، بما يترتب عليه إلحاق ضرر «خاص بالمتعاقد»، لا يشاركه فيه من مسهم هذا الإجراء»، بما يستوجب التعويض الكامل عن آثار هذا الإجراء، ويراجع في التعريف السابق، فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بتاريخ ١٩٦٤/١١/٢٨، مشار إليها لدى د. جابر جاد نصار- مرجع سابق ص ٢٤٢.

أما نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة، فيقصد بها أن يواجه المتعاقد مع جهة الإدارة أثناء تنفيذ تعاقد «صعوبات مادية» استثنائية لم تكن متوقعة عن إبرام التعاقد، بما يترتب عليه أن يصبح التنفيذ أكثر كلفة ومشقة، وغالباً ما تجد تلك النظرية مجال إعمالها في عقود الأشغال العامة، كأن يفاجأ المتعاقد أثناء التنفيذ، بصعوبات مادية في بيئة التنفيذ ذاته لم تكن في حسابه، كأن يُصادف بيئة صخرية أثناء الحفر، أو بيئة غير صالحة للبناء دون معالجتها أثناء البناء، أو غير ذلك من صعوبات مادية استثنائية لم تكن مقدرة عند إبرام التعاقد، بما يقتضي على الإدارة هنا تعويضه تعويضاً كاملاً عما تكبده نتيجة تلك الصعوبات المادية غير المتوقعة.

وثانيها: أن يكون من شأن هذه الظروف إصابة المتعاقد بخسائر فادحة تجاوز الخسارة العادية التى يمكن احتمالها، على نحو تختل معه اقتصاديات العقد اختلالاً جسيماً...»⁽¹⁾.

كما أكدت كذلك على أن «تطبيق نظرية الظروف الطارئة في مجال العقود الإدارية وروابط القانون العام، أمر رهين بأن تطرأ خلال مدة تنفيذ العقد تلك الظروف، وأن يكون ذلك خلال تلك المدة وليس بعدها»⁽²⁾.

كما أنه فيما يخص شرط عدم استحالة التنفيذ، قضت المحكمة بأنه «يشترط لإعمال نظرية الظروف الطارئة ألا يكون تنفيذ الالتزام مستحيلاً، وإنما تجعل تنفيذه أكثر عبئاً وأثقل كلفة مما قدره المتعاقدان، بحيث يهدد المدين بخسارة فادحة أي مرهقاً للمدين»⁽³⁾.

2- يشترط في الظرف الطارئ كذلك أن يكون مفاجئاً غير متوقع وفق السير الطبيعي للأمر، أثناء إبرام التعاقد، كما لا يمكن دفعه.

وفي ذلك تؤكد المحكمة الإدارية العليا على أنه «يشترط لتطبيق نظرية الظروف الطارئة أن تطرأ خلال مدة تنفيذ العقد الإداري، حوادث أو ظروف طبيعية أو اقتصادية من عمل جهة إدارية غير الجهة المتعاقدة أو ظروف من عمل إنسان آخر، لم يكن في حسابان المتعاقد عند إبرام العقد توقعها، ولا يملك لها دفعاً»⁽⁴⁾.

ذلك أن هذه النظرية لا تطبق «إذا كان خطأ المتعاقد قد وقع في أمور متوقعة قبل تنفيذ العقد وفقاً للسير الطبيعي للأمر للنظام المعتاد للعمل في الإدارة العامة»⁽⁵⁾.

3- أن يترتب على الظرف الطارئ إخلال جسيم باقتصاديات العقد، بما يجعل تنفيذه أكثر كلفة وإرهاقاً، بما يقتضيه ذلك من وجوب النظر إلى مكونات العقد في مجموعها، بحيث تكون اقتصاديات العقد في مجموعها قد أصابها خلل جسيم، أما إن كان هذا الخلل قد طال عنصراً من عناصر العقد أو بنداً من بنوده دون غيره مع بقاء غيرها من البنود لم تصب بذلك الخلل، بحيث يبقى في النهاية أن اقتصاديات العقد ما زالت عادلة ومتوازنة، فإنه لا مجال هنا لإعمال مقتضى نظرية الظروف الطارئة، إذ إنه يجب النظر دوماً إلى اقتصاديات العقد في مجموعها كوحدة واحدة، يكمل بعضها بعضاً.

- ١ حكم المحكمة الإدارية العليا في ١٩٨٥/١١/٣٠، طعن رقم ٢٥٤١ لسنة ٢٩ ق. عليا.
- ٢ حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعين رقم ٨٤٣ و ٩٢٢ لسنة ٣٦ قضائية في ١٩٨٢/١١/٢٠، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا والجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في العقود الإدارية في أربعين عاماً من أول أكتوبر سنة ١٩٥٥ إلى آخر سبتمبر سنة ١٩٩٥، صادرة عن المكتب الفني لمجلس الدولة بمناسبة اليوبيل الذهبي للمجلس، ص ٤٥٨، ومشار إليهما أيضاً لدى د. محمد عبد المجيد إسماعيل- عقود الأشغال الدولية والتحكيم فيها- منشورات الحلبي الحقوقية طبعة ٢٠٠٣، ص ٢٧٧، كما يراجع في ذات الصدد أيضاً حكمها في الطعين رقم ٤٦٦٩ و ٥٠٨٧ لسنة ٤١ ق. عليا، بجلسة ١٩٩٧/١١/٢٥.
- ٣ حكم المحكمة الإدارية المصرية في الطعين رقم ٤٦٦٩ و ٥٠٨٧ لسنة ٤١ ق. عليا، بجلسة ١٩٩٧/١١/٢٥.
- ٤ حكم المحكمة الإدارية العليا في ١٩٨٧/٥/١٦، طعن رقم ٣٥٦٢ لسنة ٢٩ ق. عليا.
- ٥ حكم المحكمة الإدارية المصرية في ١٩٩٣/٤/٤، طعن رقم ٤٥٩ لسنة ٣٥ ق. عليا.

وفيما يخص هذا الشرط، قضت المحكمة الإدارية العليا بأن «نظرية الظروف الطارئة، مقتضاها أن يطرأ خلال مدة تنفيذ العقد الإداري حوادث وظروف طبيعية كانت أو اقتصادية لم تكن في الحسبان عند التعاقد ولا يملك معها المتعاقد دفعاً، ومن شأنها أن تنزل خسائر فادحة تخل باقتصاديات العقد إخلالاً جسيماً، شريطة أن يتم تنفيذ العقد الإداري تنفيذاً كاملاً»⁽¹⁾.

كما نوهت المحكمة على الضوابط الواجب مراعاتها عند تقدير التعويض عن تلك الظروف، مشترطة أنه «في تقدير مدى الإخلال الحادث في العقد بسبب الظروف الطارئة، يتعين الأخذ في الاعتبار بجميع عناصره المؤثرة في اقتصادياته، ومنها كامل قيمة العقد ومدته، فيفحص في مجموعه كوحدة واحدة دون الوقوف على أحد عناصره - أساس ذلك : أنه قد يكون في العناصر الأخرى ما يجزئ ويعوض المتعاقد عن العنصر أو العناصر الخاسرة، ومؤدى ذلك أن التعويض الذي تلتزم به جهة الإدارة، لا يستهدف تغطية الربح الضائع أيًا كان مقداره، أو الخسارة العادية المألوفة في التعامل، وإنما أساسه تحمل الجهة الإدارية المتعاقدة لجزء من خسارة محققة وفادحة، تدرج في معنى الخسارة الجسيمة، بفرض إعادة التوازن المالي للعقد بين طرفيه، في سبيل المصلحة العامة»⁽²⁾.

4- يشترط لإعمال نظرية الظروف الطارئة كذلك، استمرار المتعاقد مع الإدارة في تنفيذ التزاماته التعاقدية، على الرغم مما تكبده بسبب تلك الظروف من مزيد إرهاق أو كلفة ومشقة، مع احتفاظه بحقه - في ذات الوقت - في الرجوع على جهة الإدارة المتعاقدة بالتعويض عما لحق من مضار، رضاءً كان ذلك أو قضاءً.

وفي هذا الصدد تقرر المحكمة الإدارية العليا أنه «ليس مؤدى تطبيق نظرية الظروف الطارئة بعد توافر شروطها، أن يمتنع المتعاقد فوراً عن تنفيذ التزاماته الواردة بالعقد، ولكن على المتعاقد أن يدعو الإدارة المتعاقدة معه لمشاركته في تحمل نصيب من الخسارة التي حاقت به نتيجة تنفيذ العقد في ظل الظروف الطارئة، فإذا رفضت، كان عليه أن يلجأ إلى القضاء لإلزام الإدارة بالتعويض المناسب»⁽³⁾.

ذلك أن «تطبيق نظرية الظروف الطارئة، يفترض بداءة أن يتم تنفيذ العقد تنفيذاً كاملاً، فإذا لم يرق المتعاقد بتنفيذ التزاماته التعاقدية كاملة، فليس ثمة محل لطلب التعويض»⁽⁴⁾.

الآثار المترتبة على تحقق الظروف الطارئة:

يترتب على تحقق الظروف الطارئة بشروطها سالف الإشارة إليها، وجوب إعادة التوازن المالي للعقد الإداري، من خلال قيام جهة الإدارة بتعويض المتعاقد معها عن المضار التي لحقت من جراء تحقق تلك الظروف، «وغاية

١ حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية في ٢٠٠١/٥/٨، طعن رقم ٥٩٥٥ لسنة ٤٣ ق. عليا.
٢ حكم المحكمة الإدارية العليا في ١٩٨٧/٥/١٦، طعن رقم ٣٥٦٢ لسنة ٢٩ ق. عليا، وكذلك حكمها في ١٩٩٣/٤/٤، طعن رقم ٤٥٩ لسنة ٣٥ ق. عليا.
٣ يراجع في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في ١٩٨٥/١١/٣٠، طعن رقم ٢٥٤١ لسنة ٢٩ ق. عليا.
٤ حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم ١٢٢٣ و ١٢٢٤ لسنة ٢٧ قضائية في ١٩٨٤/١٢/١٨، مجموعة الأربعين عامًا في العقود الإدارية - مرجع سابق، ص ٤٤٦، مشار إليه لدى د. محمد عبد المجيد إسماعيل- مرجع سابق، ص ٢٧٧.

هذا التعويض -وفقاً لما تقرره المحكمة الإدارية العليا- هو استمرار المرفق العام في تأدية الخدمة المنوط به أداؤها للمواطنين⁽¹⁾.

ضوابط إعادة التوازن المالي للعقد الإداري بناء على تحقق الظروف الطارئة:

لقد أقر الفقه والقضاء الإداري عدداً من الضوابط المتعلقة بتعويض المتعاقد مع الإدارة بغية إعادة التوازن المالي للعقد الإداري حال تحقق الظروف الطارئة⁽²⁾، وسواء قامت الإدارة بأداء التعويض بصورة توافقية، أو تم إلزامها به عن طريق القضاء، وتتمثل تلك الضوابط فيما يلي:

1- أن التعويض يكون تعويضاً جزئياً ينصب على الخسائر الفعلية أو المحققة التي حاقّت بالمتعاقّد مع الإدارة.

2- أنه لا يجوز للمتعاقد مع الإدارة المطالبة بالتعويض استناداً إلى ربح فاته أو بسبب نقص في قيمة المكاسب التي كان يرجوها، ذلك أن التعويض الذي تلتزم به جهة الإدارة، لا يستهدف تغطية الربح الضائع أياً كان مقداره، أو الخسارة العادية المألوفة في التعامل.

3- أنه يجب في تقدير مدى الاختلال الحادث في العقد بسبب الظروف الطارئة، الأخذ في الاعتبار بجميع عناصره المؤثرة في اقتصادياته، ومنها كامل قيمة العقد ومدته، فيفحص في مجموعه كوحدة واحدة دون الوقوف على أحد عناصره، أساس ذلك أنه قد يكون في العناصر الأخرى ما يجزئ ويعوض المتعاقد عن العنصر أو العناصر الخاسرة.

وعلى هذه الضوابط السابقة الواجب مراعاتها في التعويض المستهدف إعادة التوازن المالي للعقد الإداري نتيجة الظروف الطارئة، أكدت المحكمة الإدارية العليا على أنه من شأن الظروف الطارئة، أن تنزل بالمتعاقّد مع جهة الإدارة خسائر فادحة تختل معها اقتصاديات العقد اختلالاً جسيماً، فإذا ما توافرت شروط هذه الظروف، «التزمت جهة الإدارة المتعاقدة بمشاركة المتعاقد معها في تحمل نصيب من خسائره، ضماناً لتنفيذ العقد على الوجه الذي يكفل حسن سير المرافق العامة بانتظام واضطراد، فنظرية الظروف الطارئة تقوم على فكرة العدالة المجردة، التي هي قوام القانون الإداري، كما أن هدفها تحقيق المصلحة العامة، فرائد الجهة الإدارية هو كفالة حسن سير المرافق العامة باستمرار وانتظام، وحسن أداء الأعمال والخدمات المطلوبة وسرعة إنجازها، كما أن هدف المتعاقد مع الإدارة هو المعاونة في سبيل المصلحة العامة، ذلك بأن يؤدي التزامه بأمانة وكفاية، لقاء ربح أو أجر عادل، وهذا يقتضي من الطرفين التساند والمشاركة للتغلب على ما يعترض تنفيذ العقد من

١ في هذا المعنى د. محمد عبد المجيد إسماعيل- مرجع سابق، ص ٢٧٤.

٢ يراجع في هذا الشأن على سبيل المثال، د. محمد عبد الحميد أبو زيد - مرجع سابق ص ٢١٩ وما بعدها، ود. جابر جاد نصار -مرجع سابق، ص ٢٦٧ وما بعدها، كما تراجع في الشأن حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم ٤٦٦٩ و ٥٠٨٧ لسنة ٤١ ق.عليا بجلسة ١٩٩٧/١١/٢٥، وحكمها في ١٩٨٧/٥/١٦، طعن رقم ٣٥٦٢ لسنة ٢٩ ق.عليا، وحكمها في ١٩٨٧/٥/١٦، طعن رقم ٣٥٦٢ لسنة ٢٩ ق.عليا، وحكمها في ١٩٨٥/١١/٣٠، طعن رقم ٢٥٤١ لسنة ٢٩ ق.عليا، وحكمها في ٢٠٠١/٥/٨، طعن رقم ٥٩٥٥ لسنة ٤٣ ق.عليا، وحكمها في ١٩٦٧/١١/٢٥، طعن رقم ١١٨٦ لسنة ١٠ ق.عليا.

صعوبات وما يصادفه من عقبات، ويكون من حق المتعاقد المضار أن يطلب من الطرف الآخر مشاركته في هذه الخسارة التي تحملها، فيعوضه عنها تعويضاً جزئياً، وهذا التعويض لا يشمل الخسارة كلها، ولا يغطي إلا جزءاً من الأضرار التي تعين المتعاقد، فإن المدين ليس له أن يطالب بالتعويض بدعوى أن أرباحه قد نقصت، أو لفوات كسب ضاع عليه، كما أنه يجب أن تكون الخسارة واضحة متميزة، ومن ثم يجب لتقدير انقلاب اقتصاديات العقد واعتبارها قائمة، أن يدخل في الحساب جميع عناصر العقد التي تؤثر في اقتصادياته، واعتبار العقد في ذلك وحدة واحدة ويفحص في مجموعه، لا أن ينظر إلى أحد عناصره فقط، بل يكون ذلك بمراعاة جميع العناصر التي يتألف منها، إذ قد يكون بعض هذه العناصر مجزئاً ومعوّضاً عن العناصر الأخرى التي أدت إلى الخسارة»^(١).

إذا كان ما سبق، إلا أنه -في تقديري- أن تلك الضوابط المقررة في شأن تقدير التعويض المستهدف إعادة التوازن المالي للعقد الإداري نتيجة الظروف الطارئة، هي مبادئ محل نظر، فيما تقرره من تعويض جزئي، أو فيما تقرره من حصر التعويض في مجرد الخسارة، وعدم جواز مطالبة المتعاقد عن التعويض عن كسب أو ربح فاته، إذ إن تلك المبادئ في الواقع تتعارض ومبادئ العدالة المجردة التي ما فتئ القضاء الإداري يرددها، بوصفها سنداً لتعويض المتعاقد عن آثار تلك الظروف، وذلك فضلاً عن تعارض تلك المبادئ كذلك مع التوقعات المشروعة للمتعاقد، في تحقيق بعض الأرباح والمكاسب من وراء تعاقد مع الإدارة، وهو ما سنلقي عليه مزيداً من البيان في معرض الحديث التالي عن الأساس القانوني لإعادة التوازن المالي للعقد الإداري في ضوء مبدأ التوقع المشروع.

المبحث الثاني

الأساس القانوني لإعادة التوازن المالي للعقد الإداري في ضوء التوقع المشروع

غالباً ما يتم تناول الأساس القانوني لفكرة إعادة التوازن المالي للعقد الإداري، استناداً إلى أمرين، يتمثل أولهما: في مبدأ الحفاظ على دوام سير المرفق العام بانتظام واضطراد، وما يقتضيه ذلك من وجوب مشاركة جهة الإدارة في آثار الظروف الطارئة التي أصابت تنفيذ العقد الإداري، فجعلته أكثر كلفة وإرهاقاً للمتعاقد معها، وذلك حرصاً منها على إتمام تنفيذ تلك التعاقدات بالصورة المرجوة، التي تمكن المرافق العامة ذات العلاقة بتلك التعاقدات من الاستمرار في تقديم خدماتها على الوجه المعتاد بها، وثاني هذين الأساسين الذي يُستند إليهما لتقرير إعادة التوازن المالي للعقد الإداري، هو مبدأ العدالة المجردة، والذي يناهضه، أن تترك جهة الإدارة المتعاقد معها وحيداً في مجابهة آثار تلك الظروف الطارئة، بما أحدثته له من إخلال جسيم باقتصاديات العقد، مع كون تلك الظروف لم تكن متوقعة عند إبرام التعاقد، كما أنه ما كان يملك لهذه الظروف ردّاً ولا دفعاً.

إذا كان ذلك، إلا أنه يمكن القول إن هناك أساساً آخر يمكن أن تستند إليه فكرة إعادة التوازن المالي للعقد الإداري -فضلاً عن هذين الأساسين- ألا وهي فكرة التوقع المشروع.

١ حكم المحكمة الإدارية العليا في ١٩٩٣/٤/٤، طعن رقم ٤٥٩ لسنة ٣٥ ق. عليا، وفي ذات الاتجاه أيضاً حكمها في ١٩٨٧/٥/١٦، طعن رقم ٣٥٦٢ لسنة ٢٩ ق. عليا.

التوقع المشروع كأحد عناصر الأساس القانوني لإعادة التوازن المالي للعقد الإداري:

تعد فكرة التوقع المشروع إحدى صور مبدأ الأمن القانوني الواجب مراعاتها من قبل سلطات الدولة عند التعامل مع المخاطبين بالقواعد القانونية، تشريعية كانت تلك القواعد أو إدارية، بما يقتضي ابتداءً التطرق لمفهوم مبدأ الأمن القانوني بصورة عامة، قبل تناول فكرة التوقع المشروع على سبيل التخصيص.

مفهوم فكري الأمن القانوني والتوقع المشروع بصورة عامة:

يقصد بمبدأ الأمن القانوني⁽¹⁾ عمومًا، ضرورة التزام السلطات العامة بتحقيق قدر من الثبات النسبي للعلاقات القانونية، وحد أدنى من الاستقرار للمراكز القانونية المختلفة، بهدف إشاعة الأمن والطمأنينة بين أطراف العلاقات القانونية من أشخاص قانونية عامة وخاصة، بحيث تتمكن هذه الأشخاص من التصرف باطمئنان على هدى من القواعد والأنظمة القانونية القائمة وقت قيامها بأعمالها، وترتيب أوضاعها على ضوء منها، دون التعرض لمفاجآت أو تصرفات مباغتة صادرة عن السلطات العامة، يكون من شأنها زعزعة هذه الطمأنينة أو العصف بهذا الاستقرار، كأن تقرر السلطات العامة تطبيق قواعد قانونية جديدة تشريعية أو لائحية بأثر رجعي يترد إلى الماضي، أو أن تقرر المساس بالحقوق المكتسبة للأفراد التي استمدوها بطريق مشروع من القوانين القائمة، أو أن تصطدم القواعد القانونية الجديدة مع التوقعات المشروعة للأفراد، والتي تكونت لدى هؤلاء بناء على أسس موضوعية مستمدة من الأنظمة القائمة وسياسات الدولة المعلنة رسميًا، والوعود المقدمة من الحكومة، والتأكيدات والتقريرات الصادرة عنها⁽²⁾.

أو بمعنى آخر فإن الأمن القانوني هو «ضمانة أو حماية تهدف إلى استبعاد الاضطراب في مجال القانون، أو التغييرات المفاجئة في تطبيقه»⁽³⁾.

ولبدأ لأمن القانوني صور وتطبيقات متعددة، سواء على المستوى التشريعي⁽⁴⁾، أو على المستوى الإداري فيما يتعلق بمجال إصدار القرارات الإدارية⁽⁵⁾.

١ للمزيد حول مفهوم الأمن القانوني وصوره في المجال التشريعي، راجع د. يوسف عبد المحسن عبد الفتاح- رقابة المحكمة الدستورية العليا على السلطة التقديرية للمشرع- رسالة دكتوراه- كلية الحقوق جامعة القاهرة - ص ٢٣٤ وما بعدها.

٢ د. يسري محمد العصار «بتصرف»، - الحماية الدستورية للأمن القانوني في قضاء المحكمة الدستورية -مجلة الدستورية التي تصدرها المحكمة الدستورية العليا - العدد الثالث- السنة الأولى - يوليو ٢٠٠٣ ص ٥١، ومشار إليه أيضًا لدى د. يوسف عبد المحسن عبد الفتاح- مرجع سابق ص ٢٣٦.

٣ د. محمد محمد عبد اللطيف- مبدأ الأمن القانوني - بحث منشور بمجلة البحوث القانونية والاقتصادية - كلية الحقوق جامعة المنصورة - العدد ٣٦ - أكتوبر ٢٠٠٤ ص ٨٨، كما مشار إليه أيضًا لدى د. يوسف عبد المحسن عبد الفتاح- مرجع سابق ص ٢٣٦.

٤ راجع في بيان صور الأمن القانوني في المجال التشريعي ورقابة المحكمة الدستورية على مدى مراعاة المشرع في تحقيقها من عدمه، د. يوسف عبد المحسن عبد الفتاح- رقابة المحكمة الدستورية العليا على السلطة التقديرية للمشرع- مرجع سابق، من ص ٢٣٤-٣٠٦.

٥ لمزيد من البيان حول بعض صور الأمن القانوني فيما يتعلق بالقرارات الإدارية، راجع د. محمد عبد اللطيف - مبدأ الأمن القانوني- مرجع سابق، ص ١٢٤ وما بعدها.

مفهوم فكرة التوقع المشروع:

تعد فكرة التوقع المشروع أو الثقة المشروعة، من أهم تطبيقات مبدأ الأمن القانوني في المجالين التشريعي أو الإداري على السواء، ويقصد بفكرة التوقع المشروع أو الثقة المشروعة عمومًا «ألا تصدر القواعد التشريعية - قانونية كانت أو لائحية - بطريقة فجائية أو مباغته للأفراد، فتصطدم مع توقعاتهم المشروعة، والتي بنوها على أسس موضوعية استنادًا إلى تشريعات قائمة، أو بناء على سياسات رسمية معلنة من جانب السلطات العامة، أو وعود وتأكيدات صادرة عنها⁽¹⁾، وبناء عليه، يمكن القول إن الثقة المشروعة تهدف إلى حماية ثقة المخاطبين بالقواعد أو قرارات الدولة، من خلال التمتع بالحق في ثبات المراكز القانونية القائمة استنادًا إلى هذه القواعد أو القرارات ولو لمدة معينة، فالثقة المشروعة إذن، تعني تمكين الفرد من التطور في وسط قانوني مستقر ومتوقع يمكنه أن يثق فيه⁽²⁾.

ولقد اعتدت المحكمة الدستورية العليا المصرية بفكرة التوقع المشروع أو الثقة المشروعة في العديد من أحكامها⁽³⁾، بما يمهّد لتلك الفكرة عمومًا لأن تكون محل مراعاة وموضع حماية عند إجراء كافة التصرفات القانونية، تشريعية كانت أو تنفيذية، بل ووجوب مراعاة حمايتها قضائيًا عند الفصل في المنازعات القضائية ذات الصلة.

فكرة التوقع المشروع في نطاق إعادة التوازن المالي للعقد الإداري:

وبتطبيق ما سبق من فكرتي التوقع المشروع بصفة خاصة، والأمن القانوني بصفة عامة، على مجال العقود الإدارية، وخاصة في النطاق الذي نحن بصده، وهو نطاق إعادة التوازن المالي للعقد الإداري، يمكن القول إن فكرة التوقع المشروع تصلح أساسًا طبيعيًا ومنطقيًا لتعويض المتعاقد مع الإدارة، حال اختلال اقتصاديات العقد نتيجة الظروف الطارئة.

ذلك أن المتعاقد مع الإدارة ما أقدم على التعاقد معها بالأساس، إلا وتحذوه توقعات مشروعة في تحقيق بعض الأرباح والمكاسب من وراء تنفيذ تعاقداته مع الجهات الإدارية، خاصة وأنه يضع في حسبانها أنها تعاقدات آمنة، بمعنى أن جهة الإدارة حتمًا ستلتزم بالتزاماتها المادية المنصوص عليها بالعقد دون مماطلة أو تنصل منها، وذلك فضلًا عن كونها تتسم بأنها الطرف الأكثر ملاءة وقدرة من الناحية المادية، مما يحفز على الدخول معها في

١ في ذات المعنى د. بسري محمد العصار - مرجع سابق ص ٥٥.

٢ د. محمد محمد عبد اللطيف - مرجع سابق - ص ٩١.

٣ يراجع للمزيد حول مفهوم التوقع المشروع أو الثقة المشروعة في المجال التشريعي ورقابة المحكمة الدستورية على مدى مراعاتها، د. يوسف عبد المحسن عبد الفتاح - مرجع سابق، ص ٢٤٥ وما بعدها، كما تراجع في ذات الصدد أحكام المحكمة الدستورية العليا ذات العلاقة والمشار إليها لديه، ومنها: حكم المحكمة الدستورية العليا في ١٩٩٧/٥/٣، طعن رقم ١٧ لسنة ١٨ ق. دستورية، وحكمها في ٢٠٠٠/١٢/٢، طعن رقم ٢٢٧ لسنة ٢١ ق. دستورية، وحكمها في ٢٠٠٠/٥/٦، طعن رقم ٨٧ لسنة ٢٠ ق. دستورية، وحكمها في ٢٠١٢/١٠/١٤، طعن رقم ٧٩ لسنة ٢٢ ق. دستورية، وحكمها في ٢٠٠٠/٧/٨، طعن رقم ٥٢ لسنة ٢٠ ق. دستورية، و المحكمة الدستورية العليا في ١٩٩٩/١٠/٢، طعن رقم ١٢٦ لسنة ٢٠ ق. دستورية، وحكمها في ٢٠٠٦/٦/١١، طعن رقم ٣٠٨ لسنة ٢٤ ق. دستورية، وحكمها في ١٩٩٧/٢/١، طعن رقم ٦٥ لسنة ١٧ ق. دستورية، وحكمها في ١٩٩٨/٢/٧، طعن رقم ٤٠ لسنة ١٥ ق. دستورية، وحكمها في ٢٠٠٠/٦/٣، طعن رقم ١١٦ لسنة ٢١ ق. دستورية، وحكمها في ٢٠١٣/٥/١٢، طعن رقم ٢٢٩ لسنة ٢٩ ق. دستورية. وحكمها في ١٩٩٣/١/٢، طعن رقم ٢٣ لسنة ١٢ ق. دستورية، وحكمها في ٢٠٠٥/٣/١٣، طعن رقم ٢٢١ لسنة ٢٤ ق. دستورية، وحكمها في ٢٠٠٣/١١/٢، طعن رقم ١٨٧ لسنة ٢٠ ق. دستورية، وحكمها في ٢٠١٣/٥/١٢، طعن رقم ٢٢٩ لسنة ٢٩ ق. دستورية.

تلك التعاقدات، يضاف إلى ذلك، أن تلك التوقعات المشروعة التي استهدفها المتعاقد من وراء تعاقد، الأصل أنها مؤسسة على حسابات دقيقة، ودراسات جدوى مستندة إلى الظروف الاقتصادية والسياسية المحيطة بهذا التعاقد.

فإن حدثت وطرات ظروف طارئة ما، لم يكن في وسع المتعاقد توقعها أو درؤها، فأخلت باقتصاديات العقد وتوازنه المالي، فهنا تأتي فكرة إعادة التوازن المالي للعقد الإداري، حماية لتلك التوقعات المشروعة التي حدثت بالمتعاقد ابتداءً للدخول في هذا التعاقد مع جهة الإدارة.

ذلك أن المتعاقد مع الإدارة، لا بد أن يشعر بأمن وطمأنينة تجاه أية تقلبات غير متوقعة قد تطرأ ويكون من شأنها أن تؤثر على تنفيذ العقد المبرم بينه وبين الإدارة، وذلك ضماناً لأن يقوم بذلك التنفيذ بكفاءة وأمانة، وبالطريقة التي تؤدي إلى استقرار المرفق العام وتحقق أقصى فائدة مرجوة منه على خير وجه، ومن مقتضيات ذلك التنفيذ على هذه الهيئة، أن يأمن آثار تقلب الظروف المحيطة بتعاقداته بصورة تعصف بتوقعاته المشروعة، بتقرير ما يقتضي تعويضه عنها حال حدوث ذلك، وبما يحقق له الأمن القانوني الكافي والكامل لتنفيذ العقد وتحقيق آثاره وفقاً لما كان يتوقعه بصورة مشروعة من تحقيق مكاسب مقبولة دفعته للإقدام على التعاقد مع الإدارة، هذا من ناحية، كما أنها تكفل له التنفيذ بالكفاءة التي تحافظ على دوام سير المرفق العام في تقديم خدماته بانتظام واضطراد منشودين من ناحية أخرى.

بل إنه يمكن القول أيضاً إن فكرة الحفاظ على دوام سير المرفق العام بانتظام واضطراد في تقديم خدماته المتعددة إلى فئات المجتمع على اختلاف مطالبهم وحاجياتهم، تعد تطبيقاً أو مظهرًا من مظاهر التوقع المشروع للمواطنين في مجموعهم، إذ إنهم يتوقعون من المرافق العامة تقديم خدماتها المرجوة بانتظام واضطراد، وعلى وجه مريض، ومن ثم فإن إحداث خلل بهذه التوقعات وهذا الاستمرار في تقديم الخدمات المرجوة نتيجة عدم تعويض المتعاقد وإفلاته من عثرته، بل وتعويضه عن توقعاته المشروعة في الربح العادل، يعد إخلالاً بمقتضيات الأمن القانوني الواجب توافرها لأفراد المجتمع ذوي العلاقة بتلك الحاجيات والخدمات التي تقدمها تلك المرافق.

ومن ثم يمكن القول أيضاً إن فكرة الحفاظ على دوام سير المرفق العام بانتظام واضطراد، قد تجد لها سنداً هي الأخرى -من هذه الزاوية- في مفهوم فكرة الأمن القانوني بمفهومه العام، من حيث وجوب الحفاظ على ديمومة سير المرفق العام بانتظام واضطراد وعلى الوجه المطلوب، هذا من ناحية، في الوقت ذاته التي تجد لها مكاناً من الناحية المقابلة في مفهوم فكرة التوقع المشروع لجمهور المواطنين المتوقعين الحصول على الخدمات المرجوة من هذا المرفق محل التعاقد، بالصورة المثلى التي تشبع احتياجاتهم منه، على الوجه الذي يرجونه.

وبناءً عليه، يمكن القول أيضاً أن إعمال مبدأ إعادة التوازن المالي للعقد الإداري تأسيساً على فكرة التوقع المشروع، بل وعلى فكرة الأمن القانوني في مجملها، يترتب عليها تحقيق أمن قانوني مستحق، سواء لدوام أداء المرفق العام بانتظام واضطراد، أو كضمان للمتعاقد مع الإدارة في الحفاظ على توقعاته المادية المشروعة التي كانت دافعاً له إلى التعاقد مع الإدارة بالأساس، بما توفر له هذه الضمانة من بيئة استثمارية آمنة نسبياً، من خلال إحاطته بضمانة التعويض عن توقعاته المشروعة، تجاه تقلبات بعض الأحداث غير المتوقعة، وبما يصب

في نهاية المطاف في تحقيق الهدف الأسمى للإدارة، والمتمثل في ديمومة استمرار مرافقها المختلفة بأداء خدماتها المنوط بها تقديمها لجموع المستفيدين منها، بالصورة المرجوة، وبانتظام واضطراد منشودين.

ومن ثم نخلص إجمالاً إلى القول بأن مبدأ إعادة التوازن المالي للعقد الإداري حال تحقق ظروف طارئة على تنفيذه، يمكن رده إلى أسس ثلاثة هي:

1- **مبدأ العدالة المجردة:** ذلك أن العدالة تقتضي ألا يتحمل المتعاقد مع الإدارة آثار تحقق تلك الظروف وحده، بما يمثله له ذلك من خسائر أو إرهاق وكلفة، مع كونه لم يكن بحسبانه توقع تلك الظروف عند التعاقد، كما ليس بإمكانه دفعها حال تحققها، مما يقتضي تعويضه عما لحق به من ضرر، سواء تمثل هذا الضرر في تحقيق خسارة، أو فوات مكسب أو ربح كان يتوقع تحقيقه توقعاً مشروعاً.

2- **مبدأ الحفاظ على دوام سير المرفق العام بانتظام واضطراد:** فالحفاظ على دوام سير المرفق العام بانتظام واضطراد، يقتضي «تيسير» تنفيذ العقد في ظل الظروف الطارئة المؤدية إلى الإخلال باقتصاديات العقد، ذلك أن عدم إقامة هذا التوازن بصورة عادلة فعلاً، سيترتب عليه عدم قدرة المتعاقد مع الإدارة على تنفيذ التزاماته، أو تنفيذها بغير الكفاءة والدقة المطلوبة، ومن ثم عدم إشباع الحاجات المطلوبة للمستفيدين من هذا المرفق بالصورة المرجوة، وذلك فضلاً عن توجس ومن ثم إحجام المتعاقدين من الإقدام على التعاقد مع الإدارة مستقبلاً، خشية تكرار ذات الظروف وعدم وجود مساندة عادلة من جهة الإدارة للمتعاقدين معها، مما يدفعهم إلى مجال آخر من التعاقدات أكثر أماناً وأقل مخاطرة، وربما أكثر ربحاً، بما ينعكس أثره بالتبعية على سير المرافق العامة مستقبلاً، من خلال إحجام المتعاقدين الأكفاء عن التعاقد معها من ناحية، أو حصر عدد المتعاقدين معها في عدد ضئيل، ربما يستغل ذلك في رفع تكلفة تلك التعاقدات من ناحية ثانية، بما يمثل عبئاً مادياً على الإدارة في قابل تعاقداتها .

3- **فكرة التوقع المشروع، بما تحققه من أمن قانوني عام:** إذ إنه -في تقديري- أن تلك الفكرة، تمثل أساساً مقبولاً ومزدوجاً لإعمال فكرة إعادة التوازن المالي للعقد الإداري، سواء بالنسبة للإدارة أو بالنسبة للمتعاقدين معها على حد سواء، ذلك أن فكرة حماية التوقع المشروع، تتضمن المعنى الحقيقي للأساسين السابقين -العدالة المجردة، وسير المرفق العام بانتظام واضطراد- في آن واحد .

فهي بالنسبة للمتعاقد تحقق له مبدأ العدالة، لكونها تحميه من مخاطر الظروف الطارئة، من حيث إنها تضمن له مساندة الإدارة له -ليس فقط في تحمل الخسائر الناتجة عن تلك الظروف- بل وتحمي توقعه -المعقول- في الكسب المشروع والمناسب في ذات الوقت، بما يحقق مبدأ العدالة في أدق معانيه .

كما أنها بالنسبة لجهة الإدارة، تحقق لها غايتها السامية المتمثلة في الحفاظ على دوام سير المرفق العام بانتظام واضطراد، ومن ثم إشباع حاجات المواطنين بالخدمة محل التعاقد، في جو من الاستقرار وعدم القلق من تأثر أدائه .

وذلك فضلاً - ومن ناحية أخرى- عما يترتب على ذلك كله من أمن قانوني، يؤدي إلى بثّ الطمأنينة والاستقرار في نفوس المتعاقدين مع الإدارة، من حيث إنهم سيجدون مساندة أكيدة وعادلة من قبل الإدارة إن طرأت ظروف طارئة لم تكن متوقعة عند التعاقد، بما يضيف نوعاً من الاستقرار على تنفيذ تلك العقود في جو من عدم التوجس من تقلبات الظروف الاقتصادية غير المتوقعة، بما ينعكس بالتبعية على حرصهم على إبرام تعاقدهم مع الإدارة وهم مطمئنون، كما يؤدي بهم ذلك أيضاً إلى تنفيذهم لتعاقداتهم مع الإدارة على الوجه الأمثل، وذلك فضلاً عن حرص المتعاقدين مع الإدارة على أن يكسبوا ثقتها فيفوزوا مستقبلاً بتلك التعاقدات، بوصفها تعاقدات آمنة مستقرة، دون الخشية من أن تكون العقود الإدارية وما تتضمنه من الشروط التي تنطوي عليها من استخدام وسائل القانون العام، منفرة للأفراد من أن يتعاقدوا معها، وكل ما سبق ينعكس بالضرورة على دوام سير المرفق العام بانتظام واضطراد، ومن ثم تقديم خدماته على الوجه المرجو منه تقديمه، وهو ما يعني -كما سبق- أن فكرة التوقع المشروع بما تحققه من أمن قانوني هنا، تصلح أن تكون أساساً مزدوجاً لكل من طرفي العقد الإداري، سواء لجهة الإدارة أو للمتعاقدين معها على حد سواء.

تعليق على مبدأ التعويض الجزئي وعدم جواز التعويض عن كسب أو ربح متوقع:

لما كان ما سبق من تناول مفهوم فكرة حماية التوقع المشروع للمتعاقدين مع جهة الإدارة، فضلاً عن أنه كان قد سبق القول أيضاً عند بيان ضوابط إعادة التوازن المالي للعقد الإداري إنه من المستقر عليه من ضوابط التعويض المترتب على حدوث الظروف الطارئة، أن هذا التعويض يجب أن يكون جزئياً، بمعنى أن «هذا التعويض لا يشمل الخسارة كلها، ولا يغطي إلا جزءاً من الأضرار التي تعين المتعاقد، وأن المدين ليس له أن يطالب بالتعويض بدعوى أن أرباحه قد نقصت، أو لفوات كسب ضاع عليه»⁽¹⁾.

إلا أنه -في تقديري- أن تلك الضوابط المقررة للتعويض عن الظروف الطارئة، هي ضوابط محل نظر، ذلك أنه إن كانت فكرة إعادة التوازن المالي للعقد الإداري تستند في أساسها -ضمن ما تستند إليه كما سبق- إلى مبادئ العدالة المجردة، فإن تلك العدالة تقتضي تعويض المتعاقد عن المكسب أو الربح الفائت، كما يتم تعويضه عما تكبده من خسائر، سواء بسواء، حتى إنه وإن كان مقبولاً عقلاً ألا يكون هذا التعويض عن الربح الفائت تعويضاً كاملاً، إلا أنه ليس من المقبول عقلاً إهماله بالكلية⁽²⁾.

خاصة إذا أخذنا في الاعتبار، أن هذا الكسب الفائت، كان متوقعاً -غالباً- بناء على دراسات منطقية وفقاً للبيئة والظروف التعاقدية السائدة -اقتصادية كانت أو سياسية- إبان إبرام التعاقد، وهو ما يعني أن حدوث ظروف طارئة مناقضة لتلك الدراسات والتوقعات، هو عصف للتوقعات المشروعة للمتعاقد لسبب أجنبي لا يد له فيه،

١ حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية في ١٩٩٣/٤/٤، طعن رقم ٤٥٩ لسنة ٣٥ ق. عليا، وفي ذات الصدد أيضاً حكمها في ٢٠٠١/٥/٨، طعن رقم ٥٩٥٥ لسنة ٤٣ ق. عليا.

٢ يتعلق بعض الفقه على فكرة التعويض الكامل عن كل ما لحق بالمتعاقد مع الإدارة في معرض حديثه عن الأساس القانوني للتعويض عن الظروف الطارئة بقوله: «يتأسس التعويض الذي يناله المتعاقد مع الإدارة في رأي البعض، على فكرة التوازن المالي للعقد الإداري، على أن الأخذ بهذا الرأي يستدعي بطبيعة الحال، أن تعوز الإدارة المتعاقد معها تعويضاً كاملاً غير منقوص عن كل الأضرار التي تسببها الظروف الطارئة، وهو أمر لم يقل به أحد، فالتعويض الذي يستحقه المتعاقد مع الإدارة في مثل هذه الحالة، لا يخرج عن كونه إعانة تهدف إلى إقالة عثرته، ومشاركته في جزء من خسارته»، د. جابر جاد نصار- الوجيز في العقود الإدارية- مرجع سابق، ص ٢٧٦.

إذا ما كان له حيلة في توقعه ابتداءً، ولا في دفعه انتهاءً، بما يقتضي تعويضه عما فاتته من كسب حقيقي ومشروع، وذلك على خلاف المستقر عليه في هذا الشأن.

ذلك أنه مما ينافي مقتضيات العدالة، كما ينافي أيضاً مقتضيات الحفاظ على التوقع المشروع للمتعاقدين، أن يُهمل تماماً ما استهدفه من ربح أو مكسب كان يرجوه من وراء تعاقد، على الرغم من أجنبية السبب الذي أدى إلى العصف بتوقعه المشروع، وإلا وقعنا في مغبة الآثار السلبية التي يمكن أن تترتب على إهمال التوقعات المشروعة للمتعاقدين مع الإدارة مستقبلاً - والسابق الإشارة إليها - وسواء تعلق تلك الآثار السلبية بالمتعاقدين ذاتهم من ناحية فقدانهم للأمن القانوني وعدم الاستقرار تجاه تلك التعاقدات، ومن ثم إمكانية إحجام المتعاقدين الأكفاء عن التعاقد مع الإدارة، أو سواء تعلق بالتأثير السلبي على مبدأ دوام سير المرفق العام ذاته بانتظام واضطراد، نتيجة عدم التنفيذ بالصورة المرجوة للعقود محلها، ومن ثم التأثير على الخدمة التي يقدمها للمستفيدين منه.

كما أن إهمال تعويض المتعاقدين - ولو جزئياً - عن توقعه المشروع في تحقيق بعض الربح، في الوقت الذي يكون فيه ملتزماً بتنفيذ كافة التزاماته التعاقدية تجاه المرفق بما يحقق للمرفق استدامة سيره المرجوة، في الوقت ذاته الذي يُهمل فيه كل توقع مشروع له في ربح أو مكسب كان دافعاً له بالأساس للتعاقد مع الإدارة، فإن ذلك يجعل تنفيذ هذا التعاقد - على الرغم من استطالة مدة تنفيذه غالباً - هو في الواقع بمثابة تنفيذ بلا مقابل، وهو أمر يتنافى بلا جدال مع فكرة العدالة المجردة التي تستند إليها نظرية الظروف الطارئة ضمن ما تستند إليه.

صحيح أن جهة الإدارة هي الأخرى قد تكبدت قيمة التعويض المترتب على الظروف الطارئة زيادة عما كان متفقاً عليه من التزاماتها المادية، إلا أنها في النهاية تبقى هي الطرف صاحب القدرة والملاءة في التعاقد، ويبقى التعاقد معها هو الطرف الأضعف دوماً، سواء مقارنة بجهة الإدارة بصورة عامة بوصفها الأقدر على تحمل آثار تلك الظروف غير المتوقعة، أو سواء بما تملية طبيعة مركز المتعاقدين في العقود الإدارية، من كونه الطرف الأضعف الذي يقابل طرفاً قوياً غير مكافئ له وهو الإدارة، بما يستخدمه هذا الطرف الأخير من أدوات السلطة العامة وفقاً لما تملية طبيعة العقود الإدارية ذاتها، بما يقتضي ويحتم على هذا الطرف المليء أيضاً بحمل ذلك التعويض، فضلاً عن تحمله لبعض ما توقعه المتعاقد من كسب أو ربح فاتته نتيجة الظروف الطارئة، وذلك حماية لدوام سير المرفق العام من جهة، وحفاظاً على التوقعات المشروعة للمتعاقدين معها من جهة ثانية، وإعمالاً لمقتضيات العدالة المجردة التي تتنافى مع تنفيذ العقد لصالحها بلا مقابل من ناحية ثالثة.

وهو ما يستدعي - في تقديري - إعادة النظر في هذا المبدأ المستقر عليه قضائياً من حصر التعويض المترتب على الظروف الطارئة، في نطاق الخسارة فقط، دونما اعتبار للأرباح والمكاسب الفائتة التي كان يتوقع المتعاقد مع جهة الإدارة تحقيقها.

ذلك أنه وكما تؤكد المحكمة الإدارية العليا ذاتها، أن «نظرية الظروف الطارئة تقوم على فكرة العدالة المجردة التي هي قوام القانون الإداري، كما أن هدفها تحقيق المصلحة العامة، فرائد الجهة الإدارية هو كفالة حسن سير المرافق العامة باستمرار وانتظام، وحسن أداء الأعمال والخدمات المطلوبة وسرعة إنجازها، كما أن هدف

المتعاقد مع الإدارة هو المعاونة في سبيل المصلحة العامة، ذلك بأن يؤدي التزامه بأمانة وكفاية، لقاء ربح أو أجر عادل، وهذا يقتضي من الطرفين التساند والمشاركة للتغلب على ما يعترض تنفيذ العقد من صعوبات، وما يصادفه من عقبات»⁽¹⁾.

المبحث الثالث

المعالجة القضائية والتشريعية للظروف الاقتصادية الطارئة المترتبة على تعديل سعر الصرف

ربما يكون من أكثر آثار التقلبات الاقتصادية تأثيراً على تنفيذ العقود الإدارية، هو ما يعترى هذه التعاقدات من ظروف اقتصادية طارئة تتمثل في إحداث تقلبات على سعر صرف العملة، بما قد يؤدي إليه ذلك - أحياناً - إلى مضاعفة قيمة التنفيذ الفعلي للعقود، عما كان متفقاً عليه وقت إبرامها وفقاً لأسعار العملة التي كانت سائدة وقت التعاقد.

وفيما يلي نلقي الضوء سريعاً على موقف القضاء الإداري المصري من حيث الاعتراف بتقلبات سعر الصرف بوصفها من قبيل الظروف الاقتصادية الطارئة المؤثرة على تنفيذ العقود الإدارية، ومن ثم المستوجبة للتعويض عن آثارها من عدمه، على أن ننثي على ذلك بالتعريض على معالجة المشرع المصري لآثار تحرير سعر الصرف بمقتضى قانون «تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة» رقم ٨٤ لسنة ٢٠١٧ بهدف إعادة التوازن المالي لتلك العقود، وهو ما نتناوله في مطلبين متتاليين كما يلي:

المطلب الأول

موقف القضاء الإداري المصري من اعتبار تقلبات سعر الصرف ظرفاً طارئاً

لقد أُنِج للقضاء الإداري المصري مرات عديدة أن يوضح موقفه من مدى اعتبار تقلبات الأسعار أثناء مدة تنفيذ العقد الإداري من قبيل الظروف الاقتصادية الطارئة المستوجبة للتعويض من عدمه، ويمكن إيجاز موقف مجلس الدولة المصري في هذا الصدد فيما يلي:

أولاً: موقف الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة:

• اعتدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة في إحدى الفتاوى الصادرة عنها باعتبار تعديل سعر الصرف يعد من قبيل الظروف الطارئة التي تستوجب التعويض عن إخلالها باقتضائيات العقد الإداري، حيث أفتت في هذا الصدد بأن «قرار مجلس الوزراء بتخفيض قيمة الجنيه المصري بالنسبة إلى الدولار، يعد حادثاً استثنائياً عاماً في حكم المادة ٢/١٤٧ من القانون المدني، إذ لم يكن في وسع المتعاقدين

١ حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية في ١٩٩٣/٤/٤، طعن رقم ٤٥٩ لسنة ٣٥ ق. عليا، وإن كان من اللافت للنظر أن المحكمة ورغم تأكيدها على مبدأ العدالة وحماية الربح والأجر العادل للمتعاقد، وفقاً لما هو مشار إليه بعالية، إلا أنها عقت على ذلك مباشرة، بتأكيدا على عدم جواز المطالبة إلا بالتعويض الجزئي، عما لحق المتعاقد من خسائر، دون حق المطالبة بأي ربح فاته من جراء تلك الظروف، فقد أردفت المحكمة مباشرة على ما هو مشار إليه بالمتن بقولها، «ويكون من حق المتعاقد المضار أن يطلب من الطرف الآخر مشاركته في هذه الخسارة التي تحمّلها، فيعوضه عنها تعويضاً جزئياً، وهذا التعويض لا يشمل الخسارة كلها، ولا يغطي إلا جزءاً من الأضرار التي تعين المتعاقد، فإن المدين ليس له أن يطالب بالتعويض بدعوى أن أرباحه قد نقصت، أو لفوات كسب ضاع عليه»، يراجع حكمها سالف الإشارة إليه.

توقعه وقت إبرام العقد، ومع التسليم الجدلي بأنه كان مفروضاً على المتعاقد أن يتوقع التجاء الحكومة إلى خفض قيمة العملة المصرية، فإن مدى هذا التخفيض لم يكن من المستطاع التكهّن به، ومن ثم فإنه يتعين أن تكون نتائج هذا الإجراء ومدى تأثيره في التوازن المالي للعقد، قد جاوز ما كان مفروضاً أن يتوقعه المتعهد حين العقد، وفي الحالتين إن كانت خسارة المتعهد من هذا الإجراء قد جعلت تنفيذ التزامه أمراً مرهقاً مهدداً له بخسارة فادحة، كان على الطرف الآخر أن يشاركه في تلك الخسائر بالقدر الذي يحد منها ويردها إلى الحد المعقول، بمعنى أن الخسارة المتوقعة، يتحملها المتعهد، أما الخسارة غير المتوقعة، فيشاركه فيها الطرف الآخر بالقدر الذي يخفف من فداحتها^(١).

• إلا أنه - وعلى خلاف ذلك - فإنه في فتاوى متعددة أخرى، رفضت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، اعتبار تقلبات سعر الصرف من قبيل الظروف الطارئة المستوجبة للتعويض، ومن قبيل ذلك ما أفتت به من أنه قد «استظهرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إفتاءها المطرد على أن تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه، وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، هو أصل عام من أصول القانون، يطبق في العقود الإدارية شأنها في ذلك شأن العقود المدنية، ومقتضى تطبيقه في الحالات التي يتفق فيها طرفا العقد على سعر إجمالي لمقاولة الأعمال، لا يستنهض للمقاول حقاً في تقاضي أية زيادة في الأجرة المتفق عليها، ولو بلغ ارتفاع أسعار المواد الأولية وأجور الأيدي العاملة وغيرها من التكاليف حداً يجعل تنفيذ العقد عسيراً»^(٢).

ثانياً: موقف المحكمة الإدارية العليا من اعتبار تقلبات سعر الصرف ظرفاً طارئاً:

إذا كنا قد استظهرنا مما سبق أن هناك تضارباً في فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة في مدى اعتبار تقلبات سعر الصرف من قبيل الظروف الطارئة التي يمكن التعويض عنها من عدمه، فإن قضاء المحكمة الإدارية العليا في هذا الشأن، لم يفارقه أيضاً ذات التضارب.

• فلقد اعتدّت المحكمة الإدارية العليا في بعض أحكامها باعتبار أن تقلبات سعر الصرف بما يترتب عليه من زيادة أعباء المتعاقد مع جهة الإدارة، تعد من قبيل الظروف الطارئة التي يجب تأمين من يتعاقد مع الجهات الإدارية ضدها، مثلها في ذلك مثل كل تغيير في الضرائب أو الرسوم الجمركية بعد تقديم العطاء وحتى تمام التوريد، حيث قضت في هذا الصدد، «بأن تتحمل الجهة المتعاقدة بقيمة الفرق في حالة زيادة الضرائب أو الرسوم الجمركية عما كانت عليه خلال الفترة الواقعة بين تقديم العطاء وآخر موعد للتوريد، دون تفرقة بين ما إذا كان سبب هذه الزيادة هو زيادة التعريفة الجمركية أو زيادة سعر الصرف الذي كانت تحسب الرسوم الجمركية على أساسه، بحسبان أن الحكمة من تحمل قيمة الزيادة في الحالتين واحدة، وهي تأمين من يتعاقد مع الجهات الإدارية ضد كل تغيير في الضرائب أو الرسوم الجمركية بعد تقديم العطاء وحتى تمام التوريد،

١ فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع رقم ٣٦٠ في ١٧/٧/١٩٥٤، الموسوعة الإدارية الحديثة، الجزء ١٨، الطبعة الأولى ١٩٨٦-١٩٨٧، ص ٧٩٦ قاعدة رقم ٥٦٨، مشار إليها لدى د. محمد عبد المجيد إسماعيل- عقود الأشغال الدولية والتحكيم فيها- منشورات الحلبي الحقوقية طبعة ٢٠٠٣، ص ٢٧٨-٢٧٩.

٢ فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع رقم الفتوى ١٢٧، في ١٧/١/١٩٩٣، الملف رقم (٧٨-٢-٢٥)، وفي ذات الاتجاه فتواها رقم ١٨٧ في ١٩٩٣/١/٣١، (الملف رقم ٤٧-١-١٥٩).

شريطة أن يتم التنفيذ في الموعد المحدد دون تأخير، وأن يُسَدَّدَ فعلاً المَقَاوِلُ أو المتعهدُ الرسومَ الجمركية بالفئات الجديدة»^(١).

كما «ميزت المحكمة الإدارية العليا - في هذا الصدد - بين الحادث الطارئ والقوة القاهرة، فأوضحت أن ارتفاع الأسعار أثناء تنفيذ العقد الإداري بطريق غير متوقع مما يترتب عليه زيادة أعباء المتعاقد بتحميله خسائر فادحة إلى حد الإخلال بتوازن العقد إخلالاً جسيماً، يعتبر ظرفاً طارئاً وليس قوة القاهرة»^(٢).

• إلا أنه وعلى خلاف ما سبق، فإن المحكمة الإدارية العليا - وفي أحكام متعددة لها - لم تعتبر تقلبات سعر الصرف من قبيل الظروف الطارئة التي تستوجب تعويض المتعاقد مع جهة الإدارة عنها حال إخلالها باقتصاديات العقد، ومن ثم اشترطت المحكمة لتقضي للمتعاقد بالتعويض عن تقلبات سعر الصرف، أن يكون هناك اتفاق بالعقد يقرر مبدأ التعويض عن تقلبات وفوارق الأسعار، بما يعنيه ذلك من أن القضاء بالتعويض هنا مرجعه عائد إلى إرادة طرفي العقد، وليس استناداً إلى نظرية الظروف الطارئة.

وتطبيقاً لذلك، قضت المحكمة الإدارية العليا بأنه من أهم حقوق المتعاقد مع الإدارة، حصوله على المقابل المالي الذي قد يكون ثمناً للبضائع الواردة أو الأشغال المتعاقد على تنفيذها أو للخدمة المطلوبة، وإنه «من المسلم به أن الشروط التي تتعلق بتحديد المقابل النقدي في العقد بصفة عامة، هي شروط تعاقدية، من ثم تتحدد بدقة وقت التعاقد، ولا يستطيع أحد طرفي العقد كأصل عام تعديلها إلا بموافقة الطرف الآخر، وسلطة الإدارة في التعديلات لا تنصب إلا على الشروط المتعلقة بتسيير المرفق العام، وليس من بينها تلك التي تحدد المقابل النقدي في العقد الإداري، ولهذا فإن الشروط المتعلقة بالمقابل النقدي في العقد تنسم بطبيعة الاستقرار، ويجد ذلك أصله في أن التزامات كل طرف من أطراف العقد تتحدد وقت التعاقد، حيث يقدر كل طرف في هذا الوقت المقابل الذي يطلبه ويسعى إليه كنتاج لما يقدم للطرف الآخر ويحقق به التوازن المالي للعقد، فإذا ما حدد المقابل في تاريخ التعاقد بنسبة معينة من قيمة الأعمال، فإن هذه النسبة وبالقيمة المحددة لها تكون من ثوابت العقد، بإعتبار النص عليها في حقيقة الأمر نص على شروط تعاقدية، وذلك دون نظر إلى تقلبات السوق أو العملة أو التعريفات الجمركية وغيرها من المسائل المتوقعة حدوثها لدى التعاقد مع الإدارة، والقول بغير ذلك يؤدي بحكم الضرورة واللزوم إلى زيادة القيمة عن المتفق عليه في حالة زيادة سعر التحويل للعملة، أو نقصان هذه القيمة في حالة نقصان سعر التحويل للعملة، وهو أمر يتناقض مع ثبات شرط المقابل المالي للعقد، ويجعل التزامات طرفيه في هذا الخصوص التزامات غير محددة، بإعتبار أن السعر قد حدد بصفة نهائية في اللحظة التي يتم فيها إبرام العقد، وبالتالي لا يجوز للمتعاقد المطالبة بفرق سعر مرجعه إلى زيادة سعر العملة عند مراحل التنفيذ المستقبلية، بإعتبار أن ذلك يؤدي إلى زيادة أعباء الإدارة، وإلى زيادة قيمة المقابل النقدي للعقد، وهو أمر غير جائز كأصل عام، ولا يتم الأخذ به إلا استثناءً وبنص تعاقدية خاص، قائم على الرضاء المشترك لطرفي العقد، ...»

١ حكم المحكمة الإدارية العليا في ١١/٥/١٩٩٣، في الطعن رقم ٣٤٣٨ و ٢٧٣٢، لسنة ٣٥ ق. عليا.

٢ حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم ٢١٥٠ لسنة ٦ قضائية، في ١٩/٦/١٩٦٢، مجموعة الأربعين عاماً في العقود الإدارية - مرجع سابق، ص ٤٥٨، مشار إليه لدى د. محمد عبد المجيد إسماعيل - مرجع سابق، ص ٢٧٧.

ومن ثم خلصت المحكمة - في ذات النزاع - إلى أنه، «وترتيباً على ما تقدم - فإن الهيئة المطعون ضدها لا تلتزم قبل الطاعن إلا بالوفاء بالقيمة المبينة في العقد المبرم بينهما، طبقاً للنسب المتفق عليها بالجنيه المصري، على أساس سعر الدولار وقت التعاقد، وهو ما تم تحديده بمبلغ ٧٠,٧ قرشاً وفقاً للسعر المعلن من البنك المركزي في هذا التاريخ، دون نظر إلى ما طرأ على هذا السعر من تغير وقت الاستحقاق، وأن ما يطالب به الطاعن من أن تكون أساس المحاسبة على أساس سعر الدولار وقت الاستحقاق وليس وقت التعاقد باعتباره يمثل خروجاً على الأصول العامة، كان يمكن تحقيقه إذا ما ضمن عطاءه تحفظاً أو شرطاً صريحاً بأن تؤدي إليه أتعابه على أساس سعر الصرف وقت الاستحقاق، وهو الأمر غير الثابت في العقد محل المنازعة»^(١).

وإعمالاً لذات التوجه، ومن قبيل المساواة في ذات القاعدة بين الإدارة والمتعاقد معها، أكدت المحكمة أيضاً على أنه لما كان المتعاقد مع الإدارة لا يجوز تعويضه عما لحقه من ضرر نتيجة زيادة سعر العملة عما كان متفقاً عليه وقت التعاقد، فإنه من حقه في المقابل الاستفادة من أي نقص يطرأ على سعر الصرف عما كان مقيماً به التزاماته وقت التعاقد، ومن ثم قضت بأنه «لما كان طرفاً عقد الصرف الذي يبرمه المداول هما المصرف والعميل، ومحلله شراء عملة أجنبية يدفع ثمنها بالجنيه المصري بسعر الصرف الرسمي يضاف إليه العلاوة المقررة، ومن ثم يتحمل العميل أية زيادة تطرأ على تلك العلاوة، كما يستفيد من أي خفض فيها، شأنها في ذلك شأن أي تغيير يطرأ بالزيادة أو النقصان على ثمن المهمات أو المواد الأولية أو أجور العمال أو أجور الشحن أو التأمين»^(٢).

ونستبين مما سبق، أن قضاء مجلس الدولة قد تردد في اعتبار تقلبات السوق وسعر العملة من قبيل الظروف الطارئة، فتارة اعتبرته الجمعية العمومية من قبيل الظروف الطارئة في افتائها، وتارة أخرى أنكرت عليه تلك الصفة^(٣)، كما أن قضاء المحكمة الإدارية العليا في ذات الشأن قد جاء كذلك متضارباً بين إثبات تلك الصفة حيناً، وإنكارها أحياناً أخرى.

وهو موقف في تقديري - محل نظر^(٤)، ذلك أن تقلبات سعر الصرف تعد من الظروف التي يصعب على المتعاقد توقعها، نظراً إلى سرعة تقلب الظروف الاقتصادية عموماً وما يصاحبها من تقلبات شديدة أحياناً في أسعار صرف العملة، فضلاً عن أن مدة تنفيذ العقود الإدارية - غالباً - ما تتسم بالطول النسبي، الذي يصعب معه التكهّن باستقرار سعر الصرف طوال مدة التنفيذ من عدمه، بما كان يستدعي من القضاء الإداري، الاعتداد بتقلبات سعر الصرف بوصفها ظروفًا اقتصادية طارئة، تستوجب التعويض عن آثارها، مع تمتع القضاء في ذات الوقت، بسلطة تقديرية في تقدير ملاسبات كل منازعة على حدة.

١ حكم المحكمة الإدارية العليا في ١٩٩٣/٨/٣١، طعن رقم ٢٥١٩ لسنة ٣٤ ق. عليا، وفي ذات المعنى أيضاً حكمها في ٢٠٠٦/٧/١٨، طعن رقم ٧٠٥٧ لسنة ٤٧ ق. عليا، وكذلك حكمها في ١٩٦٧/١١/٢٥، طعن رقم ١١٨٦ لسنة ١٠ ق. عليا
٢ حكم المحكمة الإدارية العليا في ١٩٦٧/١١/٢٥، طعن رقم ١١٨٦ لسنة ١٠ ق. عليا.
٣ قريباً من ذات المعنى، د. محمد عبد المجيد إسماعيل - مرجع سابق، ص ٢٨٠-٢٨١.
٤ ربما مما تجدر الإشارة إليه هنا، أن مجلس الدولة الفرنسي قد اعتبر أن تقلبات سعر الصرف، تعد من قبيل الظروف الطارئة التي تستوجب التعويض، طالما كان تغير الأسعار غير متوقع، «بينما رفض طلب التعويض إذا كان التغير في الأسعار في حدود المتوقع، مما لا يشكل إخلالاً كبيراً باقتصاديات العقد»، يراجع في هذا المعنى د. محمد عبد المجيد إسماعيل - مرجع سابق، ص ٢٧٤.

المطلب الثاني

المعالجة التشريعية لآثار تحرير سعر الصرف بمقتضى قانون التعويضات المصري

رقم ٨٤ لسنة ٢٠١٧

لما كان ما سبق وتطبيقاً عليه، فإنه نظراً لبعض الظروف الاقتصادية والسياسية التي مرت بها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية، فقد حدث انخفاض شديد للاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية نتيجة تأثير تلك الظروف على مصادر النقد الأجنبي، ومع زيادة الطلب عليه، أصبح هناك فارق كبير بين سعر الجنيه مقابل السعر الرسمي للعملة الأجنبية، وذلك فضلاً عن اتفاق الدولة مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض لإنعاش الاقتصاد، وما تطلبه الصندوق من شروط للموافقة على إتمام هذا القرض، إذ أدى كل ذلك إلى لجوء البنك المركز المصري في ٢٠١٦/١١/٢ إلى اتخاذ قرار بتحرير «بتعويم» سعر صرف الجنية مقابل العملات الأجنبية.

ولما كان هذا القرار قد ترتب عليه انخفاض سعر الجنية مقابل الدولار إلى النصف تقريباً، فضلاً عن ارتفاع نسبة التضخم، وهي نتائج لم تكن متوقعة أثناء إبرام العقود المختلفة مع جهات الإدارة، فقد نتج عن ذلك أضرار بالغة بالمتعاقدين مع جهة الإدارة، نتيجة تضاعف أسعار الخدمات والمواد الخام المطلوبة لتنفيذ تلك العقود، بما لم يكن متوقعاً عند إبرامها، مما كان سيؤدي بالتبعية إلى العصف بتوقعاتهم المشروعة في تحقيق أية مكاسب أو أرباح كانت متوقعة، فضلاً عن عدم قدرتهم الفعلية على تنفيذ تلك التعاقدات إلا بخسارة شديدة يتكبدونها حال إلزامهم بتنفيذها بذات قيمتها المتفق عليها عند التعاقد، مما حدا بالمشروع إلى التدخل لمعالجة تلك الآثار، من خلال إصداره لقانون «تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة» رقم ٨٤ لسنة ٢٠١٧ بهدف إعادة التوازن المالي لتلك العقود^(١).

وهو ما يعني أن المشروع المصري بهذا التدخل التشريعي، مقررًا تعويض المضارين من آثار تحرير سعر الصرف، قد اعتبر صراحة أن تحرير سعر الصرف في هذه الظروف، يعد من قبيل الظروف الاقتصادية الطارئة، التي تستوجب التعويض عن آثارها، عبر إعادة التوازن المالي للعقود محلها^(٢).

وحسناً فعل المشروع المصري بهذا التدخل التشريعي الصريح، خاصة في ظل عدم استقرار القضاء الإداري على اعتبار تقلبات سعر الصرف من قبيل الظروف الطارئة المستوجبة للتعويض عن آثارها، كما سبق بيانه.

١ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية بالعدد ٢٧ (مكرر)، بتاريخ ٢٠١٧/٧/٩.

٢ ربما مما يجدر التأكيد عليه هنا، أن التعويض عن آثار تحرير سعر الصرف وفقاً لهذا القانون، هو من قبيل التعويض عن آثار ظروف طارئة، وليس تعويضاً عن آثار نظرية عمل الأمير، وذلك لسببين، أولهما أن التعويض في حالة نظرية عمل الأمير، يكون تعويضاً عن إلحاق ضرر خاص بالمتعاقد، لا يشاركه فيه من مسهم هذا الإجراء، في حين أن آثار تحرير سعر الصرف هو تعويض عن ظرف استثنائي عام، مسّت آثاره الجميع، وفي القلب منهم المتعاقدين مع الإدارة، وثانيهما أن التعويض عن عمل الأمير، مرجعه إلى اتخاذ إجراء من جانب جهة الإدارة المتعاقدة، وهو مالا ينطبق على حالة تحرير سعر الصرف، بما مفاده أن تحرير سعر الصرف هنا هو من قبيل الظروف الطارئة التي فرضت نفسها على طرفي العقد سواء بسواء، ولم يكن في مقدور أي من الطرفين درؤه.

وإنه بالتعريض سريعاً على نصوص هذا القانون - وفي سبيل الوقوف على المنهج الذي تبناه لهذه المعالجة التشريعية لآثار تحرير سعر الصرف - نلاحظ أن تلك المعالجة التشريعية ربما تتسم بوصفها معالجة لظروف خاصة، وإن كان لها دلالتها العامة، المتمثلة في إفصاح المشرع عن قناعته بأن التقلبات الواردة على سعر الصرف، تمثل ظرفاً طارئاً يستوجب التعويض عن إخلاله بالتوازن المالي للعقد الإداري، وهي دلالة يتوجب أن يكون لها مردودها في توجهات القضاء الإداري في ذات الصدد.

وعموماً، فإن الناظر إلى نصوص القانون محل الدراسة، يجد أنه قد نص على نطاق زمني لإعمال أحكامه، كما نص على نطاق موضوعي، يتمثل في أنواع العقود التي تسري عليها تلك الأحكام، كما أشار إلى آلية تقدير نسب التعويض، وسلطة إقرارها، وإجراءات استحقاقها، وذلك وفقاً للإيجاز التالي:

أولاً: النطاق الزمني والموضوعي لإعمال أحكام قانون التعويضات رقم ٨٤ لسنة ٢٠١٧:

لقد حدد القانون نطاقاً زمنياً وموضوعياً لإعمال أحكامه، إذ قرر أن تسري أحكام هذا القانون على عقود «المقاولات والتوريدات والخدمات العامة»، التي تأثرت بالقرارات الاقتصادية الصادرة في الفترة من ٢٠١٦/٣/١ وحتى ٢٠١٦/١٢/٣١، على أن يكون تنفيذ تلك العقود كان سارياً في الفترة من ٢٠١٦/٣/١ وحتى نهاية تنفيذ العقد.

إذ قد نصت المادة (١) منه على أن «تنشأ لجنة تسمى «اللجنة العليا للتعويضات»، يكون مقرها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تختص بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة في الفترة من ٢٠١٦/٣/١ وحتى ٢٠١٦/١٢/٣١، والتي ترتب عليها الإخلال بالتوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترة، والتي تكون الدولة أو أي من الشركات المملوكة لها أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها، وذلك عن الأعمال المنفذة بدءاً من ٢٠١٦/٣/١ وحتى نهاية تنفيذ العقد، وذلك كله ما لم يكن هناك تأخير في التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد».

ويلاحظ على النص التشريعي السابق، أنه اشترط لاستحقاق التعويض عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية المشار إليها ما يلي:

1. أن يكون العقد ضمن أنواع العقود المشار إليها، وهي عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة التي أبرمتها الدولة أو أي من الشركات المملوكة لها أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة، عن الأعمال المنفذة في الفترة المشار إليها بهذا القانون.

2. أن تكون تلك العقود قد جرى تنفيذها بدءاً من ٢٠١٦/٣/١ وحتى نهاية تنفيذ العقد، حتى ولو كان تاريخ نهاية هذا التنفيذ لاحقاً على تاريخ ٢٠١٦/١٢/٣١، وأياً كان تاريخ إبرام هذه العقود^(١).

١. يراجع للمزيد حول تحديد النطاق الزمني لإعمال أحكام هذا القانون مع مزيد من التوضيح للفروض المختلفة في هذا الصدد، البند ثالثاً من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٣ لسنة ٢٠١٧، والخاص بإصدار أسس وضوابط ونسب التعويضات اللازمة لتطبيق أحكام القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠١٧، والمعتمدة من مجلس الوزراء، والمنشورة بالجريدة الرسمية بالعدد ٢٩ (مكرر ب)، بتاريخ ٢٠١٧/١٠/١.

3. أن تكون تلك العقود قد تضررت من تلك القرارات الاقتصادية، بما ترتب عليه الإخلال بالتوازن المالي لها، وهو ما يعني أن استحقاق التعويض بالنسبة للعقود المنفذة خلال تلك الفترة ليس استحقاقاً آلياً، لمجرد أنه قد تم خلال تلك الفترة.

4. يشترط لاستحقاق التعويض في جميع الأحوال ألا يكون هناك تأخير في التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد.

ثانياً: آليات وإجراءات تقدير التعويض والحصول عليه وفقاً للقانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠١٧:

نص القانون على آلية تقدير نسب التعويضات، وسلطة إقرارها، وإجراءات استحقاقها وفقاً للآليات والإجراءات الآتية^(١):

1- نص القانون على إنشاء لجنة تسمى «اللجنة العليا للتعويضات»، يكون مقرها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تختص بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات محل هذا القانون، ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وبرئاسة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية^(٢).

2- يقدم صاحب الشأن طلباً بصرف التعويض للجهة التي يحددها وزير الإسكان متضمناً ما يلزم لهذا الطلب من بيانات.

3- يعرض رئيس اللجنة على مجلس الوزراء تقريراً بالأسس والضوابط ونسب التعويضات زيادة أو نقصاناً والمدة اللازمة لصرف هذه التعويضات حسب الظروف كلما دعت الحاجة لاعتمادها وإصدار التعليمات اللازمة للعمل بها في الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون.

4- يتولى مجلس الوزراء إقرار صرف التعويضات المشار إليها بناء على تقرير يرفع إليه من اللجنة العليا للتعويضات^(٣).

وإجمالاً يمكن القول إن المشرع المصري بإصداره لقانون «تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة» رقم ٨٤ لسنة ٢٠١٧ مستهدفاً إعادة التوازن المالي لتلك العقود، قد خطا خطوة إيجابية صريحة ومحمودة، تجاه إقرار قاعدة قانونية مؤداها الاعتداد بتقلبات سعر الصرف بوصفها ظرفاً اقتصادياً طارئاً يستوجب التعويض

١ تراجع مواد القانون من (١ - ٤).

٢ صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٦٧٧ لسنة ٢٠١٧، ونشر بالجريدة الرسمية بالعدد ٢٩ مكرر (ي) بتاريخ ٢٦/٧/٢٠١٧، متضمناً تشكيل اللجنة - وفقاً لما قرره القانون - برئاسة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعضوية الأشخاص المحددة صفاتهم بنص المادة (٢) من قانون التعويضات رقم ٨٤ لسنة ٢٠١٧.

٣ تراجع قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٣ لسنة ٢٠١٧، والخاص بإصدار أسس وضوابط ونسب التعويضات اللازمة لتطبيق أحكام القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠١٧، والمنشورة بالجريدة الرسمية بالعدد ٢٩ (مكرر ب)، بتاريخ ١٠/١٠/٢٠١٧، للوقوف على المزيد من ضوابط هذه الآليات والإجراءات التي أجملها القانون.

عنه حال إخلاله بالتوازن المالي للعقد الإداري، ولا ينفي ذلك الرأي، القول بأن هذا القانون قد صدر لمعالجة ظروف خاصة، ومستهدفًا التعويض عن مضار بعض القرارات الاقتصادية خلال فترة بعينها، ذلك أن تلك المعالجة التشريعية -حتى وإن صدرت لظروف خاصة- إلا أنها لا تنفي كشفها عن توجه وقناعة لدى المشرع، اعتبر فيها -ودون موارد- أن تقلبات سعر الصرف تمثل ظرفًا اقتصاديًا طارئًا يستوجب التعويض كأصل عام، كما أن تلك الخطوة، لعلها تدفع المشرع مستقبلاً إلى إقرار ذات المبدأ بنص عام في قانون المناقصات والمزايدات.

بل لعل تلك المعالجة التشريعية التي تبناها قانون التعويضات رقم ٨٤ لسنة ٢٠١٧، يكون لها مردودها في قضاء مجلس الدولة، بأن يتبنى -ولو من باب القياس عليها- مبدأ مستقرًا في قضائه، يعتد فيه بتقلبات الأسعار غير المتوقعة، بوصفها ظرفًا طارئًا يستوجب التعويض عن إخلاله بالتوازن المالي للعقود الإدارية.

كما يمكن القول أيضًا بأن مسلك المشرع المصري في هذا الصدد، قد انطوى على احترامه للتوقعات المشروعة للمتعاقد مع الإدارة، بوجوب تعويضهم عما ألم بهم من جراء الظروف الطارئة المتمثلة في تعديل سعر الصرف، خاصة وأن المشرع في هذا القانون وكذلك في القرارات المنفذة له، لم يتحدث عن التعويض عن مجرد الخسائر التي لحقت بالمتعاقدين مع الإدارة، ولكن تحدث بصورة عامة عن استحقاق التعويض عن الأضرار الناشئة عن تلك القرارات الاقتصادية، بما يؤدي إلى إقامة التوازن المالي لتلك العقود، ومن ثم فإن إطلاق عبارة «التعويض عن القرارات الاقتصادية»، يستفاد منه معنى التعويض الكامل وليس التعويض الجزئي.

وإجمالاً، ومن جماع ما سبق، فقد تناول هذا البحث دراسة نظرية الظروف الاقتصادية الطارئة وإعادة التوازن المالي للعقد الإداري في ضوء فكرة التوقع المشروع، وقد تناول بيان مفهوم تلك النظرية، وشروط إعمالها، من حيث اشتراط حدوث ظروف طارئة لم تكن متوقعة عند إبرام التعاقد، يترتب عليها الإخلال باقتصاديات العقد إخلالاً جسيماً، يجعل تنفيذ العقد أكثر كلفة وإرهاقاً للمتعاقد -وإن لم يكن مستحيلاً-، كما تطرق البحث للآثار المترتبة على تحقق تلك الظروف، من وجوب تعويض المتعاقد مع جهة الإدارة عما لحقه من خسائر جراء تحققها، وبين البحث أنه من المستقر عليه في شأن التعويض عن تلك الظروف، أنه تعويض جزئي، تشارك به الإدارة المتعاقد معها بعض خسائره، لتقليله من عثرته، دون أن يكون له الحق في المطالبة بالتعويض عن كسب أو ربح فاته، وأكدت هذه الدراسة على أن تلك المبادئ المستقرة في شأن استحقاق التعويض، تتنافى والأسس القانونية التي تستند إليها فكرة إعادة التوازن المالي للعقد الإداري، والتي أسندتها الدراسة إلى أسس ثلاثة، هي مبادئ العدالة المجردة، وفكرة التوقع المشروع بما تحققه من أمن قانوني للمتعاقد مع الإدارة وللمرفق العام على السواء، وذلك فضلاً عن الأساس المتمثل في مبدأ دوام سير المرفق العام بانتظام واضطراد، مع بيان هذه الدراسة لمفهوم الأمن القانوني بمعناه العام، كما بينت كذلك مفهوم فكرة التوقع المشروع، بوصفها صورة من صور الأمن القانوني الواجب حمايتها بالنسبة للمخاطبين بالقواعد القانونية، تشريعية كانت أو إدارية.

كما تطرقت هذه الدراسة أيضاً إلى المعالجة القضائية والتشريعية للظروف الاقتصادية الطارئة المترتبة على تعديل سعر الصرف، وبيّنت أن موقف مجلس الدولة المصري، سواء ما تعلق منه بإفتاء الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، أو قضاء المحكمة الإدارية العليا، قد جاء متضارباً في هذا الخصوص، حيث أثبت

القضاء الإداري وصف الظرف الطارئ على تقلبات سعر الصرف حيناً، بيد أنه أنكره عليه أحياناً أخرى، وقد بيّنت الدراسة أن هذا الموقف القضائي، هو موقف محل نظر.

ثم خُتِمت هذه الدراسة بتناول معالجة المشرع المصري لآثار تحرير سعر الصرف بمقتضى قانون التعويضات المصري رقم ٨٤ لسنة ٢٠١٧، إذ عرّجت على النطاق الزمنى والموضوعي لإعمال أحكامه، وكذلك على آلية تقدير نسب التعويض المستحقة عن آثار تحرير سعر الصرف وسلطة إقرارها وإجراءات استحقاقها، مؤكدةً في الوقت ذاته على أن تلك المعالجة التشريعية وإن كانت تتسم بوصفها معالجة لظروف خاصة، إلا أنها لها دلالتها العامة، المتمثلة في الكشف عن قناعة المشرع بالاعتداد بأن التقلبات الواردة على سعر الصرف، تمثل ظرفاً طارئاً يستوجب التعويض عن إخلاله بالتوازن المالي للعقد الإداري.

وبناء على ما سبق، فإن هذه الدراسة توصي بما يلي:

- أن تُقرّ التشريعات ذات العلاقة صراحة -وكمبدأ عام- اعتبار تقلبات سعر الصرف من قبيل الظروف الطارئة المستوجبة لتعويض المتعاقد مع الإدارة، حال إخلال ذلك باقتضائيات العقد، وفقاً لضوابط عامة يكون تنفيذها تحت رقابة القضاء، وتجد هذه التوصية أهميتها في ظل تضارب أحكام القضاء وعدم استقرارها على مبدأ مستقر في هذا الصدد.
- أن يكون التعويض عن الظروف الطارئة تعويضاً كاملاً، وفقاً لظروف كل عقد على حدة، وذلك حماية للتوقعات المشروعة للمتعاقد مع الإدارة، وحفاظاً على دوام سير المرفق العام ذاته، وفقاً لما سبق إيضاحه بهذه الدراسة.
- في ظل عدم وجود نص تشريعي عام يقرر التعويض عن تقلبات سعر الصرف، فإنه حريٌّ بالقضاء الإداري، أن يستقر على مبدأ عام، مؤداه الاعتداد بأن تقلبات سعر الصرف، تمثل ظرفاً طارئاً يستوجب التعويض حال إحداثه خللاً باقتضائيات العقد، ولعل أن ما تبناه المشرع المصري بقانون التعويضات رقم ٨٤ لسنة ٢٠١٧ من إقرار جزئي لهذا المبدأ، يمهد الطرق أمام القضاء الإداري للاستقرار على مثل هذا المبدأ العام.